

KHAIROL NIZAM BIN MOHAMED

lawan

KETUA PENDAKWA SYARIE

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), Datuk Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 21hb Jun 2022 / 21 Zulkaedah 1443H

Rayuan Jenayah No. 10000-153-0007-2019

[Percubaan Melakukan Persetubuhan Bertentangan Dengan Hukum Tabii (Seksyen 52(1)(a) dan 28 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995]

Pegum Syarie Perayu : Tetuan Amirul Hani & Associates

Responden : Ketua Pendakwa Syarie Negeri Selangor

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Perayu terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang diberikan pada 7/11/2019 di dalam Kes Jenayah No.: 10100-153-0025-2019. Di dalam kes tersebut, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat perintah/hukuman seperti berikut: –

- i. *Mahkamah menjatuhkan hukuman terhadap Tertuduh, Khairol Nizam bin Mohamed (No k/p: 771106-06-5909) penjara selama tujuh (7) bulan;*
- ii. *Denda sebanyak RM4900.00 atau penjara selama empat (4) bulan sebagai ganti kepada denda sekiranya gagal bayar denda.*
- iii. *Sebatan sebanyak enam(6) sebatan yang hendaklah dilaksanakan di dalam penjara.*

[2] Perayu telah terkilan dengan sebahagian hukuman tersebut iaitu hukuman penjara selama tujuh bulan dan telah memfailkan Notis Rayuan pada tarikh yang sama. Selanjutnya Perayu telah memfailkan Petisyen Rayuan pada 28/2/2020 dan telah memplidkan 7 alasan untuk merayu seperti di halaman 191-193 Rekod Rayuan.

[3] Bagi hukuman denda dan sebatan, kedua-dua hukuman tersebut telah disempurnakan oleh Perayu sebelum perintah penggantungan diluluskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada 15/11/2019.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[4] Semasa prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah, Perayu telah membuat pengakuan bersalah, maka rayuan yang boleh dibuat hanyalah berkenaan takat hukuman yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Bicara. Ini jelas diperuntukan di dalam seksyen 136 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 sebagaimana berikut: –

‘Apabila seseorang tertuduh telah mengaku salah dan disabitkan oleh Hakim atas akuan itu, maka tiada rayuan boleh dibuat kecuali tentang takat atau kesahan hukuman itu.’

[5] Berdasarkan rekod rayuan, petisyen dan hujah rayuan Perayu serta hujah pihak Responden yang dikemukakan, kami dapati isu utama yang perlu diputuskan terlebih dahulu dalam rayuan ini adalah: –

- i. Apakah status keabsahan hukuman pemenjaraan selama 7 bulan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Bicara pada 7/11/2019.
- ii. Adakah keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes *Iki Putra bin Mubarak lwn Kerajaan Negeri Selangor [2020] 4 MLRA 1* pada 25/2/2021 memberi kesan kepada rayuan ini.

[6] Kedua-dua persoalan ini timbul apabila Mahkamah Persekutuan dalam kes *Iki Putra bin Mubarak lwn Kerajaan Negeri Selangor [2020] 4 MLRA 1* pada 25/2/2021 telah sebulat suara memutuskan bahawa seksyen 28 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995 adalah tidak berpelembagaan dan tidak sah. Keputusan tersebut adalah ekoran daripada cabaran yang dikemukakan oleh Iki Putra bin Mubarak iaitu salah seorang Tertuduh yang dituduh bersama-sama Perayu terhadap keabsahan peruntukan tersebut dari sudut perlembagaan.

[7] Mahkamah Persekutuan dalam kes tersebut antara lain menyatakan bahawa meskipun tafsiran terhadap frasa “*kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam*” (*offences against the precepts of Islam*) yang berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah merangkumi aspek yang luas, namun ia masih tertakluk kepada had-had tertentu dalam Perlembagaan.

[8] Kesalahan liwat yang menjadi subjek utama dalam kes ini termasuk dalam undang-undang jenayah (*criminal law*) dan ia terletak di bawah bidang kuasa Persekutuan. Oleh yang demikian, kes tersebut perlu diadili di Mahkamah Sivil dan dalam masa yang sama, undang-undang yang terkandung dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri dianggap tidak sah.

[9] Bagi menjelaskan kedua-dua persoalan di para [5] di atas, kami dapati hukuman telah dijatuhkan terhadap Perayu adalah pada 7/11/2019 iaitu sebelum kes Iki Putra bin Mubarak lwn Kerajaan Negeri Selangor diputuskan. Pada hemat kami keputusan tersebut tidaklah mempunyai kesan kebelakang (*retrospective effect*) terhadap hukuman yang telah dijatuhkan. Oleh yang demikian, hukuman pemenjaraan tersebut adalah masih sah, berkuatkuasa, dan terpakai menurut undang-undang yang terpakai pada waktu itu.

[10] Sungguhpun begitu, oleh kerana hukuman pemenjaraan tersebut belum dilaksanakan setelah Mahkamah Bicara membenarkan penggantungan pelaksanaan hukuman pada 15/11/2019, maka kami berpandangan bahawa ianya tidak lagi boleh dikuatkuasakan memandangkan seksyen 28 telah tidak mempunyai punca kuasa setelah diisytiharkan tidak berpelembagaan dan tidak sah mulai 25/2/2021.

[11] Prinsip umum dalam undang-undang jenayah Islam ialah seseorang itu tidak boleh dihukum atas sesuatu perlakuan jenayah jika tiada undang-undang yang menetapkan hukuman bagi jenayah tersebut ketika dilakukan. Hal ini berdasarkan dalil surah Al-Isra : 15 antara lain: –

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Dan tiadalah Kami mengazabkan sesiapaupun sebelum Kami mengutuskan seorang Rasul (untuk menerangkan yang benar dan yang salah)”

[12] Dalam membahaskan perkara berkaitan, Abdul Qadir Audah dalam kitabnya At-Tashri' Al-Jina'I Al-Islami menyatakan bahawa kaedah asas dalam perundangan Islam ialah: –

Tiada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sebelum wujudnya nas.

[13] Dalam konteks rayuan di hadapan kami ini, peruntukan seksyen 28 Enekmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1993 dianggap telah tidak wujud setelah Mahkamah Persekutuan menyatakan ianya tidak sah sekali gus menyebabkan hilangnya punca kuasa hukuman bagi kesalahan ini.

[14] Berdasarkan otoriti-otoriti ini adalah jelas bahawa perbuatan yang dilakukan sebelum wujudnya sesuatu pengharaman kepada perbuatan tersebut tidaklah memberi kesan hukuman kepada pelakunya. Pendirian Syarak berkaitan perkara ini dapat dilihat dalam banyak isu antaranya adalah larangan menikahi isteri kepada bapa sebagaimana firman Allah Taala dalam surah An-nisa : 22 –

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

[15] Ayat ini merupakan suatu tegahan daripada Allah SWT ke atas orang yang beriman agar tidak mengahwini mana-mana perempuan yang telah dinikahi oleh bapa sebagaimana amalan golongan jahiliah sebelum kedatangan Islam termasuk menghimpun dua perempuan bersaudara dalam satu perkahwinan. Walau bagaimanapun sekiranya ianya telah berlaku sebelum turunnya ayat pengharaman ini, maka ianya adalah terkecuali dan dimaafkan.

[16] Pengecualian yang diberikan oleh Syarak mengenai perbuatan masa lalu *إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ* dalam ayat ini menjadi *qiyas* kepada status hukuman yang telah

dijatuhkan oleh hakim bicara sebelum ini. Dengan mengambil kira hukuman telah dijatuhkan ke atas Perayu adalah sebelum Mahkamah Persekutuan membuat keputusan, maka hukuman tersebut secara prinsipnya adalah sah mengikut undang-undang yang terpakai pada waktu itu dan hanya terbatal selepas ianya diisytiharkan tidak sah.

[17] Manakala bagi hukuman denda dan sebatan yang telah dilaksanakan sebelum tarikh tersebut, hukuman dan pelaksanaannya tetap dianggap sah. Namun bagi hukuman pemenjaraan yang belum dilaksanakan dan menjadi asas kepada rayuan ini, maka hukuman tersebut sungguhpun ianya sah tetapi tidak lagi boleh dikuatkuasakan. Hal ini turut bertepatan dengan kaedah fiqh: –

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه

“Dalam memutuskan sesuatu pada masa itu, hukumlah dengan apa yang wujud pada waktu itu. Dan bukan menghukum dengan hukuman-hukuman yang sebaliknya.”

[18] Berdasarkan kedudukan peruntukan seksyen 28 yang kini telah terbatal dan tidak sah sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan dan prinsip-prinsip Syarak yang telah kami nyatakan, maka tiada lagi keperluan untuk kami mempertimbangkan sebarang justifikasi kepada 7 alasan untuk merayu seperti yang dikemukakan di halaman 191-193 Rekod Rayuan.

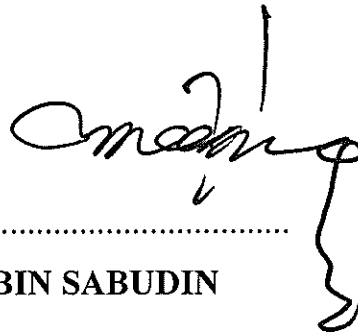
[19] Kami berpuas hati bahawa dapatan kami ini adalah selari dengan satu kes yang telah diputuskan oleh Panel Rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 25/6/2021 iaitu dalam kes Nurfaiz bin Abu Seman lawan Ketua Pendakwa Syarie Selangor, kes rayuan no. 10000-153-0004-2019 [belum dilaporkan].

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Petisyen Rayuan, Rekod Rayuan serta hujah kedua-dua belah pihak, maka kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:—

- [1] Bahawa hukuman penjara selama tujuh (7) bulan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada 7/11/2019 adalah **tidak boleh dikuatkuasakan.**

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD-LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

